추상화, 여과, 비교 테스트
; 저작권법(오승종)[1]

1. 서설

○ 전통적인 실질적 유사 판단방법(표현테스트, 청중테스트), 외관이론을 컴퓨터프로그램과 같은 기능적이고 실용적인 목적을 가지는 저작물의 침해판단에 적용하면, 저작자를 과도하게 보호하고 아울러 효율적인 경쟁을 심각하게 저해하는 위험을 야기할 수 있다.

○ 그렇다고 하여 컴퓨터프로그램에 대한 보호를 '문언적 침해'나 '데드카피'에 한정하는 것으로 제한하는 것도 문제이다.

○ 이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로 미국의 제2항소법원은 Altai 사건에서 새로운 판단기준을 개발하였다.

○ 이 방법은 비록 컴퓨터프로그램이라는 특별한 저작물에 대한 저작권 침해사건 판단을 위하여 고안된 것이지만 '기능적 저작물'이나 '사실적 저작물'과 같이 창작자와 이용자 보호의 균형과 관련하여 조심스러운 판단이 요구되는 거의 모든 저작물에 적용될 수 있는 정밀한 모델을 제공하고 있다.

2. 아이디어와 표현의 구분

○ Altai 판결은 우선 컴퓨터프로그램의 **비문언적 요소가 저작권의 보호를 받을 수 있는지 여부**에 대해 언급한다.

○ 재판부는 프로그램의 구조는 개개의 소스코드와 같은 문언적인 요소도 포함하고 있지만, 일반적인 플로우차트를 비롯하여 구체적으로는 개별 모듈을 연결하는 조직체계, 파라미터 리스트, 매크로 등과 같은 비문언적 요소까지도 포함한다고 하였다. 컴퓨터프로그램의 비문언적 요소 역시 저작권의 보호를 받을 수 있는 것이라고 하였다. 그러나 비문언적 요소라도 아이디어에 해당하는 것은 저작권의 보호를 받을 수 없으므로, 비문언적 요소 주에서 아이디와 표현을 구분해 내는 작업은 필요하다.

---

1) 오승종, 저작권법 5판, 박영사(2020), 1300쪽

○ 재판부는 "아이디어는 보호되지 ㅇ낳고 표현만이 보호된다는 저작권법의 대원칙은 컴퓨터프로그램에도 적용되어야 한다. 그런데 본질적으로 실용적이고 기능적인 성질을 가지는 컴퓨터프로그램에 있어서는 아이디어와 표현의 분리가 더욱 어렵다. 기능적 저작물에 있어서 아이디어와 표현의 구분에 관한 선례적 사건인 Baker 판결에서의 '회계서적'과 컴퓨터프로그램은 양쪽 다 특정한 결과를 가져오는 기술 또는 명령이라는 점에서 대체적으로 유사하다. 다만 전자느 사람이 그 과정을 진행하지만, 후자는 전자적인 방법에 의하여 과정이 진행된다는 차이점이 있을 뿐이다. 어쨌든 두 가지 경우 모두 작업의 프로세스 자체는 저작권의 보호를 받을 수 없는 부분이다. 그리고 Baker 판결에서와 마찬가지로, 컴퓨터프로그램의 기능을 구현하는 데 있어서 필수적으로 수반되는 요소들 역시 보호를 받을 수 없는 부분이다."

3. 추상화, 여과, 비교 테스트의 내용 => 궁극적으로, 프로그램의 '비문언적 요소' 들을 보호대상으로 하여 침해 여부를 판단하는 과정이다.

가. 기본구조

○ 전통적인 방법과 비교할 때, '추상화-여과' 단계은 아이디어-표현 이분법에 의한 구분 과정, '비교' 단계는 실질적 유사성에 대한 심리 과정에 대응된다. 이 경우 '비교' 단계는 앞의 두 단계에서 추출된 보호받는 표현들 중 어느 부분을 피고가 복제하였는가, 그리고 그 복제된 부분이 원고의 전체 프로그램과 관련하여 볼 때 상대적으로 어느 정도의 비중(중요성)을 가지고 있는가를 평가하는 작업이 중심을 이루게 된다.

○ 참고적으로 추상화, 여과, 비교의 3단계 테스트의 원칙적인 개념을 살펴보면, (추상화 단계) 먼저 원고의 프로그램을 그것을 구성하는 **구조적 부분들로** 분해하고, (여과 단계) 각각의 **분해된 부분들을 검토**(보호대상 여부에 대한 평가)하여 그에 내재된 아이디어, 그 아이디어를 나타내는 데 반드시 필요한 표현들, 공중의 영역으로부터 가져온 요소들에 해당하는 것들을 가려냄으로써 모든 보호받지 못하는 요소들을 걸러내고, (비교) **창작적 표현의 핵심적인 요소들을 피고**

프로그램의 구조와 비교(실질적 유사 여부에 대한 평가)하는 것이다.

나. 1단계: 추상화

○ 프로그램 '역분석'(reverse engineering)과 유사한 방식으로 진행된다.

○ 추상화의 낮은 단계에서 그 구조는 매우 복잡할 수 있지만, 추상화의 높은 단계에서는 아주 단순한 것이 된다.

○ 이와 같이 추상화의 가장 낮은 단계에서 파악되는 모듈 내에 들어 있는 개별 명령들을 한 단계 추상화하면, 그 모듈들의 기능단위가 개념적으로 파악될 수 있다. 이와 같이 추상화의 낮은 단계에서의 모듈과 명령들을 그 보다 상위 단계의 모듈이 가지는 기능단위로 점차 추상화 시켜 나가는 과정을 거쳐 점점 더 높은 추상화의 단계로 나아가게 되면, 결국 그 프로그램이 달성하고자 하는 최종적이고 궁극적인 기능에 도달하게 된다.

다. 2단계: 여과

○ 추상화의 각 단계에 나타나 있는 '구조적 요소' 들을 검토하여 '보호받을 수 있는 요소'와 '보호받지 못하는 요소'를 구분하는 과정이다. 이 과정에서, 아이디어인지, 합체된 표현인지가 고려된다.

○ '보호받지 못하는 요소'(='보호범위로부터 걸러지는 요소')는 다음과 같다.

(가) 효율성에 의해 지배되는 요소들

- 합체의 원칙이 적용된다.
- 어떤 특정한 명령이 원하는 작업을 수행하기 위하여 유일하고도 필수적인 것이라면 그것은 저작권의 보호를 받을 수 없다는 것을 의미한다.
- 또한 특정한 기능을 수행하기 위한 구체적인 지시나 명령을 작성하는 방법이 다수 존재한다고 하더라도, 효율성의 고려 때문에 현실적으로 채택할 수 있는 방법은 극히 제한되는 경우가 있다. 따라서 이러한 경우에 해당하는 표현은 당해 프로그램의 아이디어에 합체되어 보호를 받을 수 없다고 보는 것이다. (=사실상의 표준)

(나) 외부적 요인에 의하여 지배되는 요소들

- 필수장면의 원칙이 적용된다. 즉 외부적인 요인에 의하여 채택되는 요소들에 대하여는 저작권보호가 제한된다.

- 저작권 보호를 제한하는 외부적 요인들로서는, (i) 프로그램이 구동되는 컴퓨터의 구조적인 규격, (ii) 그 프로그램과 연계되어 함께 작동하도록 되어 있는 다른 프로그램들과의 상호운용성, (iii) 컴퓨터 제조업자들이 사용하는 디자인 표준, (iv) 관련 산업계의 요구사항, (v) 컴퓨터 업계에서 널리 받아들여지고 있는 프로그램 제작 관행 등을 들 수 있다.

(다) 공중의 영역으로부터 가져온 요소들

- 공중의 영역으로부터 가져온 요소들은 특정인만이 독점적으로 사용하여서는 안되는 요소들이므로 이들에 대하여도 저작권보호가 제한된다.

라. 3단계: 비교

- 컴퓨터프로그램의 비문언적 요소에 대한 실질적 유사성을 판단하기 위한 마지막 단계이다.
- (i) 피고가 이러한 보호받는 표현 중 어떤 부분을 복제하였는지, 그리고 (ii) 복제한 부분이 원고의 전체 저작물과 관련하여 볼 때 상대적으로 어느 정도의 중요성을 가지고 있는지, 즉 실질적인 정도에 이르었는지 아니면 사소한 정도에 그치고 있는지를 평가하게 된다.[2)]
- 이 중 (i) 판단 부분은 전통적인 판단방법 중 보호받는 표현테스트와 대응하는 것이고, (ii) 판단 부분은 청중테스트에 대응하는 것이라고 볼 수 있다.
- 이 때 두 저작물 사이의 유사성이 보호받지 못하는 표현에 기인하는 것인지 여부를 판단하기 위하여 유사성에 대한 '분석적 분해'가 수행되어야 할 수도 있다. 만약 두 저작물 사이에 존재하는 유사성이 전적으로 공통된 아잉디어의 사용에 기인하는 것이라면, 저작권침해가 성립되기 위한 요건으로서의 '실질적 유사성'은 존재하지 않는다고 판단한다.

4. Altai 판결에서 3단계 테스트의 적용 방식과 결론

가. 적용방식

○ 추상화를 ① 목적코드 및 소스코드 ② 파라미터 리스트와 매크로 ③ 요구되는

---

2) 3단계 테스트를, 침해로 주장되는 부분을 먼저 특정하고, 여과 비교하는 과정의 순서로 진행하는 경우 위 (i) 단계는 이미 추상화단계에서 이루어졌기 때문에, 이러한 방식으로 3단계 테스트를 수행하는 경우에 있어서 비교 단계에서는 위 (ii) 단계만이 이루어질 것이다.

기능 ④ 아웃라인(플로우차트)의 4단계로 추상화하고, 각 추상화단계에서 '여과' 및 '비교'과정을 통해 창작적 표현에 있어서 실질적 유사성을 평가한 후, 종합하여 평가함.

○ Altai 판결은, ①에서 동일한 코드는 사실상 존재하지 않아 코드에 있어서의 유사성은 존재하지 않는다. ② 보호받는 일부 리스트와 매크로가 유사하나 비중이 크지 않다. ③ 겹치는 부분이 있으나 연계되는 운영체계 및 응용프로그램과의 호환성을 확보하기 위하여 필요한 부분이다. ④ 프로그램의 플로우차트는 지극히 단순한 것이어서 프로그램의 작동원리를 아는 사람에게는 자명한 내용에 해당하기 때문에, 이 부분의 유사성도 큰 의미를 두기 어렵다. 결국 대상 판결은, 원고와 피고 프로그램의 파라미터 리스트 및 매크로 중 극히 일부분의 보호받는 표현에 있어서의 유사성이 있으나, 그 밖의 다른 유사한 부분들은 공중의 영역에서 가져온 것이거나 프로그램의 기능적인 요구사항을 달성하기 위하여 필수적인 요소들에 해당한다고 하였다. 그리고 보호받는 표현에 있어서의 일부 유사한 부분도 그 부분이 전체 저작물에서 차지하는 비중에 비추어 볼 때 저작권침해를 인정할 만큼 중요성을 가지고 있지 않다고 하면서, 원고의 OSCAR 3.5DP 대한 저자권 침해 주장을 기각한 지방법원의 판결을 유지하였다.

5. (실무) ① 「원고저작물을 기준으로 먼저 보호받지 못하는 것을 걸러내는 것」과, ② 「보호를 받지 못하는 부분을 걸러내기 전에 먼저 저작물의 전체로서의 비교가 이루어지는 것」의 비교

가. 저작권 침해 판단방법으로서 지금까지 알려진 어떤 방법보다도 더 정교하고 논리적인 분석 틀을 제공하고 있다고 평가받는 3단계 테스트를 적용할 때 유념하여야 할 매우 중요한 논점이다.

나. ①의 방식으로 저작물을 전체로서 비교하는 것은 저작권의 보호를 받지 못하는 요소들이라 하더라도 그것을 선택, 배열한 것에 대하여는 저작권의 보호를 부여할 수 있다는 원칙과 서로 모순되는 것처림 보인다. 왜냐하면 저작물을 비교하기 전에 저작권의 보호를 받지 못하는 부분은 여과되어 제외되기 때문이다.

다. ②의 방식을 취한다면 개별적이 구성요소와 그 전체로서의 성과물은 저작권 보호를 받는 요소와 받지 못하는 요소를 선택하여 배열한 것으로 저작권 보호를 받을 수 있다고 볼 여지가 많다.

라. (개인의견) 단, ②의 방식을 취하는 경우에 있어서, 각 공통점이 원고저작물의 추상화 어느 단계에 해당하는 것이고, 해당 단계에서 창작성을 평가하여 창작적 표현에 대해 실질적 유사성이 있는지 여부를 평가하여야 할 것이다.

[실전사례]

Apple Computer, Inc. v. Microsoft Corp., 35 F.3d 1435 (9th Cir. 1994)[3]

추상화, 여과, 비교의 3단계 테스트 관련 실무 사례(교사서에 나온 것과 차이가 있다. 즉 교과서에서 보호범위 확정 후 비교하는 방식인데, 아래 실무사례는 선비교 보호대상에 대한 평가의 순서이다) ;

; 침해를 부정함. 단, GUI가 보호대상이 아니다라고 천명한 것은 아니다.

'추상화-여과-비교'의 3단계테스트를 적용하여 저작권 침해를 구성할 만큼 보호받는 부분에 대한 복제행위가 있었는지 여부를 판단하였다.

첫째, '**추상화**'단계에서, 원고는 피고가 **복제를 한 부분을 분명히 한다**.

둘째, '**여과**'단계에서, 원고가 복제되었다고 **지적한 부분 중에서 보호받지 못하는 부분을 여과한다**(보호받지 못하는 부분: 아이디어 및 아이디어와 불가분의 관계에 있는 부분, 원고가 피고에게 라이선스를 준 부분, 당해 아이디어를 표현함에 있어서 필수적인 부분 등)

셋째, 이러한 요소들이 걸러지고 보호를 받을 수 있는 표현이 얼마나 되는지를 검토한 후에는 당해 저작물이 저작권법상 넓은 보호를 받을 것인지 아니면 좁은 보호를 받을 것인지를 결정하여야 한다. 다음으로 그 저작권의 보호범위에 따라 당해 저작물을 전체로서 비교함으로써 저작권 침해를 구성할 많나 충분한 정도의 복제행위가 있었는지 여부를 결정한다.

---

3)